

1501155-03.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... narrada na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas. Isso porque os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do denunciado, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501155-03.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501155-03.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2195903/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12912437 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 7842/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2195903 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 7842/20/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MARTINS GOMES CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LEONARDO MARTINS GOMES CARDOSO, qualificado à fls. 22/25, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 10 de agosto de 2020, no período vespertino, nesta Cidade de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado, durante estado de calamidade pública, tinha em depósito, para traficar, duzentos e onze gramas e trinta e um

decigramas (211,31g) de Tetrahydrocannabinol (THC), distribuídos em vinte e nove (29) porções, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica, conforme laudos de constatação prévia de fls. 26/27 e laudos de exame químico toxicológico de fls. 102/104 e 107/109.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, houve sua conversão em preventiva (fls. 51/52). Em sede de habeas corpus, o C. STJ determinou a soltura do réu (fls. 227/231).

A denúncia foi oferecida e o réu, notificado, apresentou defesa prévia a fls.

129/160. A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2020 (fls. 175/177).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo que o acusado, ao final, foi interrogado (fls. 196/199 e 287/294).

Em sede de memoriais escritos, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 303/311). A defesa, por sua vez, também em sede de memoriais escritos, postulou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja reconhecido o tráfico privilegiado, com início de cumprimento da pena em regime aberto (fls. 313/316).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12

e pelos laudos de exames químico toxicológicos de fls. 29/30, 105/107 e 110/112. Tais provas técnicas encontram eco nos autos, inexistindo assim qualquer resquício de dúvida quanto à ilicitude daquelas substâncias causadoras de dependência, apreendidas na ocasião.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Na delegacia de polícia, o réu afirmou que “sobre os fatos, nego que a droga que foi encontrada na casa do meu primo Guilherme Oliveira Amorim são minhas. Eu estava na casa do meu primo para pegar uma porção de maconha para meu consumo. As drogas que foram encontradas lá são do meu primo. Nego também que estava fracionando a droga para vendê-las. Nego também que tenha arremessado a droga no telhado e no terreno vizinho. O dinheiro que estava comigo, ou seja, R\$ 40,00 reais não é proveniente do tráfico de drogas. No tocante a droga que foi encontrada no meu quarto, afirmo que era para meu consumo. Meu avô e tampouco minha avó sabiam sobre a existência das drogas no meu quarto. Não sou traficante de drogas. O dinheiro que foi encontrado no meu quarto no valor de R\$ 160,00 reais eu recebi da venda de um carro que acabei de vender. Eu comprei um pedaço de maconha para meu consumo, porém os policiais apresentaram porções que não foram encontradas no meu quarto. Ou seja, eu só tinha uma porção pequena no meu quarto”.

Em juízo, afirmou que a droga que estava na casa do seu primo era de sua propriedade, mas se destinava ao seu uso. Disse que foram achadas umas “29 balinhas”. Confirmou que jogou para a casa vizinha a droga que estava em seu poder. O depoimento do acusado, contudo, não encontra amparo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução, isso porque a prova é inconteste no sentido de que o entorpecente apreendido era destinado ao comércio ilegal. Vejamos: André Savério da Silva, policial militar, afirmou que ele e Alekssander Xavier Conrado efetuavam patrulhamento pelo Bairro Jussara, quando avistaram Guilherme Alex de Souza, o qual conduzia uma motocicleta e tinha Guilherme Oliveira de Amorim na garupa. Ao notar a viatura policial, o condutor da motocicleta acelerou e ingressou na residência situada na Rua Ouro Preto nº 645, pertencente a Guilherme Oliveira de Amorim. Abordamos, mas não encontraram nada de ilícito com eles. Constataram movimentação nos fundos do imóvel, oportunidade em que o denunciado admitiu que acabara de arremessar parte do entorpecente sobre o muro da casa vizinha. Em poder dele, localizaram a importância de quarenta reais (R\$ 40,00). Sobre a mesa onde o réu estava, encontraram quatro (04) porções de maconha. No telhado e no terreno do imóvel vizinho, onde o réu arremessou algo, apreenderam vinte (20) porções pequenas de maconha e uma porção maior dessa mesma droga. Em seguida, foram à moradia do denunciado, onde, no quarto dele, dentro de uma caixa, encontraram quatro (04) grandes porções de maconha e duzentos e sessenta reais (R\$ 260,00). Na ocasião, o réu assumiu a propriedade do entorpecente e confessou o tráfico (fls. 05 e 199).

Alekssander Xavier Conrado, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, confirmando a apreensão do entorpecente (fls. 06 e 198). Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas. Isso porque os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do denunciado, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Este é o entendimento do Col. STF: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não

terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).

Como se não bastasse, os depoimentos de André Savério da Silva e Aleksander Xavier Conrado são corroborados por Guilherme Oliveira de Amorim, o qual informou que é primo do acusado e morador da residência situada na Rua Ouro Preto nº 645. Estava na garupa da motocicleta pilotada por Guilherme Alex de Souza e foram abordados por policiais militares no exato momento em que ingressavam em sua casa. O réu estava no local embalando "balinhas" de maconha para vendê-las e, ao avistar os militares, arremessou parte do entorpecente pelo muro. Fazia algum tempo que ele estava "mexendo com drogas". Acredita que, na moradia do denunciado, os agentes policiais apreenderam mais entorpecentes (fls. 118 e 289).

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa em nada esclareceram sobre os fatos. Isso porque Rogério Martins Gomes e Silvío Luis Cardoso, tio e pai do acusado, respectivamente, narraram que não presenciaram o ocorrido. Posteriormente, o réu alegou que o entorpecente não lhe pertencia (fls. 290 e 291).

Cosmo Gomes, avô do acusado, esclareceu que os policiais militares estiveram em sua casa, onde também reside o acusado, e localizaram maconha. Não sabe a quem pertencia o entorpecente (fls. 294).

Com efeito, para a configuração do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é exigida prova da mercancia dos entorpecentes, mas, sim, que a droga encontrada era para consumo por terceiros, o que ficou demonstrado pelo contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos, mormente sua quantidade e forma de acondicionamento.

Outrossim, não se está afirmando que o réu não seja usuário de drogas, já que é perfeitamente corriqueira a coexistência da figura do usuário-traficante. O que se está concluindo é que, na ocasião, o acusado tinha em depósito entorpecentes que não estavam destinados a seu consumo pessoal, mas sim, ao tráfico ilícito.

Comprovada, portanto, a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, de rigor procedência da ação a fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, c.c. o art. 42, da Lei nº 11.343/06, e tendo-se em conta a primariedade, fixo a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500(quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, incide a agravante disposta no art. 61, II, "j", do Código Penal, que se refere à calamidade pública, pois o acusado praticou delito que atenta contra a saúde pública durante a pandemia da Covid-19 que assola o país e o mundo. Salienta-se que o Congresso Nacional decretou "Estado de Calamidade Pública" por meio do Decreto Legislativo n. 06/2020, o que permite a aplicação da agravante, considerando que a conduta do réu contribuiu para o caos que ainda assola a população. Contudo, deixo de proceder a atenuação, sob pena de violação à Súmula 231 do STJ, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal.

Na terceira e última fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a reprimenda do réu em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

No caso específico dos autos, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido (211,31g de Tetrahydrocannabinol (THC), distribuídos em vinte e nove (29) porções), o que demonstra que o acusado vinha mantendo atividade

organizada à traficância, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Ademais, a fixação de regime prisional mais brando não se mostra suficiente a atender aos aspectos retributivo e preventivo da pena, não obstante a primariedade do réu. Neste sentido: "Tráfico privilegiado - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Fração redimensionada - Recurso Ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos - Recurso Ministerial provido. Regime mais gravoso - Necessidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso Ministerial parcialmente provido. Redução ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado - Reprimenda mantida - Recurso não provido. Concessão da justiça gratuita - Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500277-58.2020.8.26.0545; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021). Por outro lado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, pois estão presentes os requisitos legais que a autorizam: pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, primeira parte do CP); crime doloso não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, segunda parte do CP); ré não reincidente em crime doloso (art. 44, II do CP); a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição é suficiente (art. 44, III do CP).

Como a pena privativa de liberdade aplicada supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 01 salário mínimo.

Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei n 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LEONARDO MARTINS GOMES CARDOSO, qualificado à fls. 22/25, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso legal, em regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

O réu poderá recorrer em liberdade porque foi posto em liberdade durante o trâmite processual e compareceu aos atos a que fora intimado. Ademais, tendo em vista a substituição da pena operada, não se mostra necessária, nesse momento processual, a decretação de sua custódia cautelar.

No mais, com supedâneo no artigo 63, da Lei 11.343/06, DECRETO o perdimento do montante apreendido em favor da União, dada a vinculação deste com o ilícito perpetrado.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração da droga apreendida nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA